

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

**nr. 247.137 van 25 februari 2020
in de zaak A. 230.121/XII-8866**

In zake: de NV MEDIALED
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Anthony Poppe
kantoor houdend te 1160 Brussel
Tedescolaan 7
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

1. de GEMEENTE KNOKKE-HEIST
2. het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
STADSONTWIKKELING KNOKKE-HEIST
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Carlos De Wolf
kantoor houdend te 9680 Maarkedal
Etikhovestraat 6
bij wie woonplaats wordt gekozen
eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Charlotte De Wolf
kantoor houdend te 9000 Gent
Fortlaan 95

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 3 februari 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Knokke-Heist van 17 januari 2020 met betrekking tot de selectie in het kader van de overheidsopdracht ‘AGSO/2019/158: Plaatsen en exploiteren van informatiedragers op het openbaar domein van de gemeente Knokke-Heist [’] waarin de aanvraag tot deelname van de nv Medialed voor het perceel 1 geweigerd wordt en de nv JC Decaux Street Furniture Belgium en bvba Clear Channel Belgium uitgenodigd worden een offerte in te dienen voor het perceel 1”.

XII-8866-1/27

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partijen hebben een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 18 februari 2020, om 14.00 uur.

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Anthony Poppe, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaten Carlos De Wolf en Charlotte De Wolf, die verschijnen voor de verwerende partijen, zijn gehoord.

Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Op 28 november 2019 beslist de gemeenteraad van Knokke-Heist om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het plaatsen en exploiteren van informatiedragers op het openbaar domein van Knokke-Heist en de selectieleidraad ervan goed te keuren.

Als gunningswijze wordt gekozen voor een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

De gemeenteraadsbeslissing luidt:

“

Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te plaatsen door middel van een Europees bekendgemaakte mededingingsprocedure met onderhandeling getiteld: "PLAATSEN EN EXPLOITEREN VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST"; dat deze procedure bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase;

Overwegende dat daartoe het selectiebestek (Selectieleidraad) thans ter goedkeuring van de gemeenteraad wordt voorgelegd en gevraagd wordt om het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen om de technische specificaties en overige bepalingen van de Gunningsleidraad goed te keuren;

Overwegende dat de opdracht complex is en daartoe met inschrijvers zal worden onderhandeld tot het bekomen van de voor het bestuur economisch meest voordelige offerte; dat daartoe met toepassing van artikel 4 van de statuten en artikel 8 van de beheersovereenkomst beroep wordt gedaan op AGSO Knokke-Heist tot het begeleiden van deze procedure;

BESLUIT:

Artikel 1.

Over te gaan tot het goedkeuren van het plaatsen van de overheidsopdracht "PLAATSEN EN EXPLOITEREN VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST", door middel van een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling met voorafgaande oproep tot mededinging.

Art. 2.

Met het oog op het organiseren van de eerste fase van de procedure de Selectieleidraad AGSO/2019/158 goed te keuren.

Art. 3.

Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen tot het vastleggen van de voorwaarden voor deze opdracht en de goedkeuring van het bestek (Gunningsleidraad).

Art. 4.

Met toepassing van artikel 4 van de statuten van AGSO Knokke-Heist en artikel 8 van de beheersovereenkomst 2007-2012, afgesloten tussen het bestuur en AGSO Knokke-Heist, beroep te doen op AGSO Knokke-Heist tot het begeleiden van deze procedure.

Deze begeleiding bestaat uit het evalueren van de Aanvragen tot Deelneming, het aan het College opmaken van een gemotiveerd selectiebesluit; het ter goedkeuring voorleggen aan het College van het bestek (Gunningsleidraad); het evalueren van de offertes en het voeren van de onderhandelingen met het oog op het voorleggen aan het College van een passend gunningsvoorstel en overeenkomst.

”

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van 4 december 2019 en in het Bulletin der Aanbestedingen van 29 november 2019.

3.3. Het voorwerp van de opdracht wordt in de selectieleidraad als volgt omschreven:

“De Opdracht heeft betrekking op:

- perceel 1: zijnde het plaatsen, onderhouden en exploiteren tegen de in de Gunningsleidraad bepaalde voorwaarden op het openbaar domein van de Gemeente van minimum 25 tot maximum 30 Digitale Informatiedragers (2 m²) waarvan minstens twee met interactieve schermen;

- perceel 2: zijnde het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes waarbij één zijpaneel kan worden benut tot het plaatsen van Analoge of Digitale Informatiedragers;

gezamenlijk hierna ‘Informatiedragers’ genoemd,
en waarbij voor minstens voor perceel 1:

- de Opdrachtnemer het recht verkrijgt om binnen welbepaalde tijdseenheden via de Digitale Informatiedragers Commerciële Boodschappen of Reclame uit te zenden (zendrechten);
- en waarbij de Opdrachtgever het recht verkrijgt om binnen welbepaalde tijdseenheden of in welbepaalde omstandigheden rechtstreeks en zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer via deze Digitale Informatiedragers Publieke Boodschappen uit te zenden;
- en waarbij in of op deze Digitale Informatiedragers mogelijks sensoren of meetapparatuur worden aangebracht die de Aanbestedende Overheid in uitvoering van haar ‘Smart Cityproject’ voor haar rekening zal plaatsen, onderhouden en beheren, hierna ‘Smart City voorzieningen’ genoemd.

Er wordt een duurtijd voorzien van 10 jaar ingaande op 1/10/2020 en waarbij een tussentijdse vervanging van de elektronische schermen van de Digitale Informatiedragers moet worden uitgevoerd.

Kandidaten kunnen aanbieden voor beide of één van de percelen. De aanbesteder behoudt zich het voorrecht om al dan niet beide percelen gezamenlijk of apart toe te wijzen, desgevallend hiertoe bij het indienen van de BAFO instructies op te leggen [...].”

De vordering heeft uitsluitend betrekking op het perceel 1 van de opdracht.

3.4. In de aankondiging wordt, wat de selectiecriteria betreft, verwezen naar de selectieleidraad.

Daarin worden de vereisten inzake de technische draagkracht als volgt omschreven:

“9.2 technische draagkracht

De technische draagkracht wordt beoordeeld aan de hand van de capaciteit om de Opdracht uit te voeren, de bekwaamheid van het personeel én het voorleggen van relevante referenties. Hieruit moet blijken dat (elk van de deelnemers van) de Kandidaat over de nodige bekwaamheid beschikt om de Opdracht tot een goed einde te brengen

9.2.1 capaciteit

De Kandidaat beschrijft over welke gespecialiseerde functies of mogelijkheden hij beschikt of kan beschikken om de Informatiedragers te

plaatsen, te onderhouden en herstellen; om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren en om de rechtstreekse toegang te waarborgen die het opmaken en zenden door de Gemeente van Publieke Boodschappen zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer mogelijk maakt.

9.2.2 personeel

De Kandidaat geeft een voorstelling van de medewerkers die zullen instaan voor de uitvoering van deze Opdracht. De voorstelling bevat minstens de volgende onderdelen:

- Opgave van de naam en het CV van de projectverantwoordelijke/teamleider (met plaatsvervanger) die de Opdracht zullen bewaken en uitvoeren;
- Opgave van de naam en het CV van de eventuele adviseurs of technici, die kunnen worden ingezet voor deze Opdracht, met vermelding van de functie, specialisatie en relevante ervaring.

9.2.3 referenties

De Kandidaat dient de referenties te voegen van drie minstens gelijkaardige opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van Digitale Informatiedragers en waarbij zendtijd werd toegewezen aan de aanbesteder. De goede uitvoering van deze opdrachten wordt bij voorkeur geattesteerd door de desbetreffende Aanbesteder.”

Bovendien wordt in de selectieleidraad uitdrukkelijk voorgeschreven dat inzake de technische draagkracht minstens de volgende documenten bij de aanvraag tot deelneming dienen te worden gevoegd:

- “○ beschrijving van de technische capaciteit;
- lijst van personen belast met de Opdracht;
- Referenties van elk van de deelnemers + bij voorkeur attesten van goede uitvoering.”

3.5. Vier kandidaten dienen een aanvraag tot deelneming in.

In het selectieverslag van 16 januari 2020 van de tweede verwerende partij wordt voorgesteld om twee kandidaten, namelijk de nv JC Decaux Street Furniture Belgium en de bvba Clear Channel Belgium te selecteren en uit te nodigen tot het indienen van een offerte. Voorts wordt voorgesteld om de aanvragen tot deelneming van de verzoekende partij en de bvba Pop Media te weigeren.

Wat de kandidatuur van de verzoekende partij betreft, wordt dit als volgt gemotiveerd:

“

2.2.3 MEDIALED.NV.

SAMENWERKINGSVERBAND SELECTIECRITERIA (9)	
beroep op draagkracht derden	nee
financiële en economische draagkracht (9.1)	
bankverklaring(9.1.1.)	
Bankverklaring	ok
Instelling	Belfius
verzekering (9.1.2.)	
attest	ok
Instelling	Baloise Insurance
jaarrekening (9.1.3.)	
OMZET:	
Jaarrekening laatste drie jaar	nvt
<u>Ratio's (gemiddelde 3 laatste boekjaren)</u>	
liquiditeit acid	1,35
solvabiliteit	0,82
netto-rentabiliteit	3,33
Balanstotaal	1.046.420,33
Omzet	3.155.757,33
Winst na belasting	154.299,67
attestatie bedrijfsrevisor	COFIPARTNERS
beoordeling	ok
technische en organisatorische bekwaamheid (9.2)	
technische capaciteit (9.2.1)	
	geen beschrijving
personeel (9.2.2)	
beroep op draagkracht derden	nee
lijst van leidinggevend + essentiële medewerkers	geen beschrijving
andere entiteiten waarop beroep kan gedaan worden	nvt
referenties (9.2.3)	
beroep op draagkracht derden	nee
referenties	ok
	3 referenties zonder attestatie : Knokke-Heist; 's Gravenbrakel (2 schermen); Kerstmarkten in Oostende en in Gent; Brussel 7 schermen (LED of LCD) voor Winterpret en ook 5 schermen (LED of LCD) voor Brussel Bad.
inschrijving percelen	
	perceel 1

bespreking

De kandidaat is gekend doordat hij 16 elektronische schermen uitbaat voor de Gemeente. Evenwel laat hij na een beschrijving te geven van zijn technische capaciteit en ondersteunend personeel, noch blijkt uit enig document in welke mate hij voor de Opdracht beroep kan doen op aangewezen ondernemingen op wiens draagkracht hij beroep kan doen.

Dientengevolge kan niet worden afgeleid of de kandidaat wel in staat zal zijn om tegemoet te komen aan de eisen van het bestek die verder reiken dan het beheer van de thans door hem geëxploiteerde informatiedragers

De Kandidaat laat na verdere informatie te verschaffen, zoals geëist in de Selectieleidraad, in het bijzonder :

- 1) opgave van de medewerkers, voorstelling die minstens volgende onderdelen moet bevatten:
 - Opgave van de naam en het CV van de projectverantwoordelijke/teamleider (met plaatsvervanger) die de Opdracht zullen bewaken en uitvoeren;
 - Opgave van de naam en het CV van de eventuele adviseurs of technici, die kunnen worden ingezet voor deze Opdracht, met vermelding van de functie, specialisatie en relevante ervaring;
- 2) in welke mate hij over afdoende know-how en technische ondersteuning beschikt om te verzekeren dat de Gemeente binnen welbepaalde tijdseenheden of in welbepaalde omstandigheden rechtstreeks en zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer via deze Digitale Informatiedragers Publieke Boodschappen uit te zenden. Hiertoe verschaft de Kandidaat geen verdere toelichting, noch over de technische bekwaamheid van in te zetten personeel, de mate dat hij in softwareontwikkeling of -ondersteuning kan voorzien en de technische middelen die daartoe ter beschikking kan stellen;
- 3) in welke mate hij over de nodige technische ondersteuning beschikt om in of op deze Digitale Informatiedragers mogelijks sensoren of meetapparatuur toe te laten die de Aanbestedende Overheid in uitvoering van haar "Smart Cityproject" voor haar re-kening zal plaatsen, onderhouden en beheren, hierna "Smart City voorzieningen" genoemd

De Kandidaat levert de derhalve niet nodige overtuigingsstukken en bewijzen waaruit vastgesteld kan worden dat hij bekwaam is om op technisch vlak de diensten zoals die voor de toekomst worden verlangd te kunnen leveren.

Derhalve wordt voorgesteld om deze kandidatuur te weigeren.

”

3.6. Op 17 januari 2020 beslist het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist om dit selectieverslag goed te keuren, de aanvraag tot deelneming van de verzoekende partij en de bvba Pop Media te weigeren en de kandidaten nv JC Decaux Street Furniture Belgium en bvba Clear Channel Belgium te selecteren en uit te nodigen tot het indienen van een offerte. Dit is de bestreden beslissing.

Met een e-mailbericht en aangetekend schrijven van 20 januari 2020 wordt de beslissing inzake niet-selectie meegedeeld aan de verzoekende partij.

IV. Schorsingsvoorwaarden

4.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

4.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ (hierna: rechtsbeschermingswet) van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.

V. Onderzoek van de middelen

A. Eerste middel

Uiteenzetting van het middel

5. De verzoekende partij voert de onbevoegdheid van de steller van de bestreden rechtshandeling aan alsook de schending van het besluit van de gemeenteraad van Knokke-Heist van 28 november 2019 tot goedkeuring van de selectieleidraad, van de artikelen 235 en 236 van het decreet van 22 december 2017 ‘over het lokaal bestuur’ (hierna: decreet lokaal bestuur), evenals van artikel 13 van de statuten van AGSO Knokke-Heist (hierna: AGSO). Zij betoogt:

“Doordat de gemeenteraad van de gemeente Knokke-Heist met een beslissing van 28 november 2019 de bevoegdheid om een selectiebeslissing te nemen in het kader van deze overheidsopdracht heeft toegewezen aan AGSO.

Doordat de bestreden selectiebeslissing van 17 januari 2020 genomen werd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Knokke-Heist.

Terwijl een administratieve rechtshandeling moet genomen worden door het daartoe bevoegde orgaan.

Terwijl de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf overeenkomstig artikel 235 DLB, bij gebrek aan uitdrukkelijke delegatiebeslissing aan het directiecomité, als enige over de bevoegdheid beschikt om het autonoom gemeentebedrijf te verbinden.

Terwijl artikel 13 van de statuten van AGSO bepaalt dat de raad van bestuur over de volheid van bevoegdheid beschikt om alle handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van AGSO te verwezenlijken. Hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

Zodat de in het middel aangehaalde beginselen geschonden werden.”

Beoordeling

6. Overeenkomstig artikel 56, § 3, van het decreet lokaal bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor:

“[...]

4° het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
5° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’, vermeld in artikel 41, tweede lid, 8°;
6° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de gemeenteraad dat nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd.”

Artikel 8 van de beheersovereenkomst gesloten tussen Knokke-Heist en haar AGSO, waarnaar in de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 uitdrukkelijk wordt verwezen, luidt onder meer:

“Artikel 8. — opdrachten ad hoc

§1 De Gemeente kan AGSO specifieke opdrachten toewijzen die niet vallen onder een bijzondere samenwerkingsovereenkomst.

Dit kan onder meer voor:

[...]

- het begeleiden voor rekening van de Gemeente van complexe overheidsopdrachten en mededingingsprocedures.”

7. Uit de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 samen genomen met artikel 8 van de beheersovereenkomst lijkt op het eerste gezicht te mogen worden afgeleid dat AGSO door de gemeenteraad werd aangewezen om de procedure voor het plaatsen van de betrokken overheidsopdracht te begeleiden voor rekening van de gemeente.

De in het tweede lid van artikel 4 van deze gemeenteraadsbeslissing vermelde stappen lijken daarbij uitsluitend een verduidelijking en nadere toelichting in te houden van wat onder “begeleiding” moet worden begrepen.

In het licht van de voormelde gemeenteraadsbeslissing en artikel 8 van de beheersovereenkomst lijkt uit de zinsnede van dit artikel 4 “het aan het College opmaken van een gemotiveerd selectiebesluit” niet te kunnen worden afgeleid dat hiermee beoogd wordt om het nemen van de selectiebeslissing zelf op te dragen aan AGSO. Het besluit dient *prima facie* immers net als het bestek en de

gunningsbeslissing te worden “opgemaakt” om “aan het College” te worden voorgelegd. Het lijkt aldus in hoofde van AGSO enkel het ontwerpen te betreffen en niet het beslissen.

Evenmin lijkt uit het feit dat AGSO als aanbestedende overheid of opdrachthoudend bestuur is aangewezen in de aankondiging of de selectieleidraad te mogen worden afgeleid dat het bevoegd was om de selectiebeslissing te nemen. Dit aanwijzen lijkt geen afbreuk te doen aan de voormelde gemeenteraadsbeslissing die, het weze herhaald, steunt op artikel 8 van de beheersovereenkomst en in wezen enkel in begeleiding voorziet.

De conclusie is dan ook dat de verzoekende partij niet aantoont dat AGSO bevoegd was om de selectiebeslissing te nemen en dat het eerste middel dan ook niet ernstig is.

B. Tweede middel

Uiteenzetting van het middel

8. De verzoekende partij voert de schending aan van de artikelen 4 en 66, § 3, van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016), van artikel 4, lid 1, 5°, en artikel 5, 6°, van de rechtsbeschermingswet, van de formelemotiveringsplicht vervat in de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-handelingen’ (hierna: motiveringswet) en het materieelmotiveringsbeginsel, van het gelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Zij betoogt:

“Doordat de aanbestedende overheid de kandidatuur van verzoekende partij heeft geweerd wegens het ontbreken van inlichtingen over de kwalitatieve selectie;

Doordat zij aanvullende inlichtingen heeft gevraagd aan twee andere kandidaten wier aanvraag tot deelneming eveneens onvolledig waren;

Doordat zij een kandidatuur heeft aanvaard waarin niet werd meegedeeld voor welk perceel de kandidaat zijn aanvraag tot deelneming indiende;

Doordat zij deze keuzes niet gemotiveerd heeft;

Terwijl het gelijkheidsbeginsel, de artikelen 4 en 66, § 3, van de Overheidsopdrachtenwet vereisen dat alle kandidaten in een selectieprocedure op gelijke voet behandeld worden, in het bijzonder wanneer de aanbestedende overheid gebruik maakt van de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te vragen;
Terwijl de aanbestedende overheid haar beslissingen op een zorgvuldige wijze moet voorbereiden;
Terwijl elke selectiebeslissing moet steunen op motieven die worden uitgedrukt in de beslissing zelf en hun grondslag vinden in het administratief dossier;
Terwijl deze motieven feitelijk correct, pertinent en draagkrachtig moeten zijn;
Terwijl geen administratieve rechtshandeling kennelijk onredelijk mag zijn;
Zodat de in het middel aangehaalde bepalingen geschonden werden.”

In de toelichting bij het middel merkt de verzoekende partij in essentie op dat de aanbestedende overheid haar bij de selectie ongelijk heeft behandeld in vergelijking met de kandidaten de bvba Clear Channel Belgium en de bvba Pop Media. Zij stelt dat haar kandidatuur werd geweerd omdat zij zou hebben nagelaten een beschrijving te geven van haar technische capaciteit en het ondersteunend personeel en evenmin uit enig document zou blijken in welke mate zij zich steunt op ondernemingen op wiens draagkracht zij een beroep kan doen, zonder dat haar een vraag tot aanvulling werd gesteld.

Aan de bvba Clear Channel Belgium zou daarentegen wel de mogelijkheid zijn verleend om aan te tonen dat zij aan de vereisten inzake de financiële en economische draagkracht beantwoordde na de uiterste datum van indiening van de kandidaturen. Bovendien werd deze kandidaat geselecteerd voor beide percelen, ondanks het feit dat deze kandidaat zelfs niet had aangegeven voor welke percelen zij haar aanvraag tot deelneming had ingediend.

Zo ook werd aan de bvba Pop Media extra informatie gevraagd met betrekking tot de door haar gevoegde referenties.

Ten slotte merkt de verzoekende partij op zij wel degelijk voldoende informatie had medegedeeld om aan te tonen dat zij kon beantwoorden aan de kwalitatieve selectiecriteria. “Het enige gebrek aan informatie dat [volgens

de verzoekende partij] haar kan verweten worden bestaat uit de lijst van personen belast met de opdracht”. Wat dit laatste betreft, zo merkt de verzoekende partij op, weet de aanbestedende overheid dat het personeel van de verzoekende partij de technische bekwaamheid heeft de opdracht uit te voeren. Overigens blijkt uit de voorafgaande marktconsultatie dat de verzoekende partij de bekwaamheid voor de opdracht heeft. De verzoekende partij had dan ook de mogelijkheid moeten krijgen om haar aanvraag aan te vullen.

Beoordeling

9. In essentie voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partijen bij haar kandidatuur geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid vervat in artikel 66, § 3, wet overheidsopdrachten 2016 om aanvullende inlichtingen te vragen, terwijl zij dit bij twee andere kandidaten wel zouden hebben gedaan.

10. Uit het selectieverslag – aangehaald onder randnummer 3.5 – waar de bestreden beslissing naar verwijst, blijkt dat de verzoekende partij niet werd geselecteerd omdat zij in haar aanvraag tot deelneming heeft nagelaten, wat haar technische draagkracht betreft, een beschrijving te geven van haar capaciteit en personeel zoals nochtans vereist in de omschrijving van de selectiecriteria en de toe te voegen documenten in de selectieleidraad – zie hiervoor randnummer 3.4.

11. De aanbestedende overheid beschikt op grond van artikel 66, § 3, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016 weliswaar onder de daar vermelde voorwaarden, waaronder het gelijkheidsbeginsel, over de mogelijkheid om een kandidaat te vragen om de inlichtingen en documenten met betrekking tot de selectie aan te vullen of toe te lichten doch deze mogelijkheid is geen verplichting, ook niet samen genomen met het zorgvuldigheidsbeginsel. Het is overigens in de eerste plaats een opdracht voor de kandidaat om zijn kandidatuur met de nodige zorgvuldigheid op te stellen. Zelfs wanneer in de selectieleidraad niet uitdrukkelijk is bepaald dat bepaalde stukken op straffe van nietigheid dienen te worden toegevoegd, mag het bestuur, zo lijkt, tot de niet-selectie besluiten op grond van de loutere vaststelling dat een in het kader van de kwalitatieve selectie

uitdrukkelijk gevraagd en verplicht bij te voegen stuk door de kandidaat niet werd bijgevoegd.

12. De verzoekende partij lijkt hier voorts niet aan te tonen dat de verwerende partijen het gelijkheidsbeginsel hebben geschonden bij het bevragen van de diverse kandidaten en dit om de volgende redenen.

12.1. Wat de vergelijking met de bvba Pop Media betreft, blijkt uit het selectieverslag dat zij wel een beschrijving van haar technische capaciteit en personeel heeft toegevoegd, evenals referenties. De verwerende partijen blijken aan deze kandidaat enkel te hebben gevraagd in welke mate de referenties die in de aanvraag tot deelneming waren gevoegd, eigen waren aan de kandidaat dan wel aan de onderaannemer op wiens draagkracht zij een beroep deed maar er geen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna: UEA) voor bijbracht. De bvba Pop Media blijkt vervolgens overigens niet te zijn geselecteerd omdat zij zelf geen voldoende referenties bijbracht en zich, gelet op de afwezigheid van een UEA voor haar onderaannemer niet op de referenties van die laatste mocht beroepen.

12.2.1. Daarnaast blijkt uit het selectieverslag dat de kandidatuur van de bvba Clear Channel inzake de technische draagkracht geen problemen kende doch dat inzake de financiële en economische draagkracht er bij deze kandidaat wordt vermeld dat werd vastgesteld dat hij “de vereiste attestatie van de uit de jaarrekening af te leiden ratio’s niet bij de aanvraag tot deelneming had gevoegd en enkel met toepassing van artikel 67 § 2 van het KB Plaatsing had beperkt tot een omzetverklaring. De in de selectieleidraad gevraagde attestatie is declaratief en werd aanvullend opgevraagd. Deze attestatie, opgemaakt door E&Y, werd tijdig elektronisch overgemaakt”. Daarnaast werd ook reeds in het kader van de beoordeling van de formele regelmatigheid van deze kandidatuur in de selectieleidraad als “Incidentie” opgemerkt: “Er werd vastgesteld dat bijlage II met betrekking tot de financiële criteria onvoldoende werd ingevuld. Het gaat over een loutere attestatie uit reeds gepubliceerde jaarrekening zodat deze attestatie zonder bezwaar kan worden nageleverd”.

Op het eerste gezicht lijkt aldus in het selectieverslag zelf op transparante wijze te worden uiteengezet waarom de verwerende partijen ten

aanzien van deze kandidaat wel een verzoek tot aanvullende inlichtingen hebben overgemaakt, namelijk dat de gevraagde attestatie louter “declaratief” is.

In haar verzoekschrift gaat de verzoekende partij volledig voorbij aan deze verantwoording in het gemotiveerd selectieverslag. Aldus maakt zij op het eerste gezicht niet aannemelijk dat er op dit punt sprake is van een ongelijke behandeling van de kandidaten.

12.2.2. Wat de beweerde ongelijke behandeling betreft dat de bvba Clear Channel zou zijn geselecteerd zonder mededeling van de percelen van de opdracht waarvoor ingeschreven werd, valt op te merken dat de vermelding inzake de percelen geen selectie criterium is. Evenmin blijkt hieromtrent een vraag tot verduidelijking te zijn gesteld.

Voorts vereist het door de kandidaten in te vullen formulier “aanvraag tot deelneming” niet de opgave voor welk perceel van de opdracht zij inschrijven. Enkel het UEA, gevoegd als bijlage 4 bij het bestek, laat de kandidaten toe te vermelden “indien van toepassing, het perceel/de percelen waarop de ondernemer wil inschrijven”. Op het eerste gezicht vormt de vermelding “in[...]schrijving percelen”: “niet medegedeeld” in het selectieverslag bij de bvba Clear Channel dan ook louter de weergave van het feit dat deze kandidaat in het UEA hieromtrent geen uitdrukkelijke vermelding heeft opgenomen.

Dat de verwerende partijen in die omstandigheden geoordeeld hebben dat het vooralsnog niet nodig is om de kandidaat bvba Clear Channel hierover te bevragen, lijkt niet van aard om te besluiten dat de kandidaten bij de selectie ongelijk zouden zijn behandeld.

13. In de mate dat de verzoekende partij ook nog aanvoert dat zij voldoende informatie had gegeven om aan te tonen dat zij kon beantwoorden aan het selectie criterium van de vereiste technische draagkracht, kan zij evenmin worden gevolgd.

Dit criterium dient te worden begrepen in het licht van het voorwerp van de opdracht, zoals hiervoor weergegeven onder randnummer 3.3, en waarbij onder meer wordt vermeld dat de opdracht gaat om informatiedragers:

- “• [...] waarbij de Opdrachtgever het recht verkrijgt om binnen welbepaalde tijdseenheden of in welbepaalde omstandigheden rechtstreeks en zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer via deze Digitale Informatiedragers Publieke Boodschappen uit te zenden.”

In haar aanvraag tot deelneming blijkt de verzoekende partij met betrekking tot het selectiecriterium technische draagkracht, aspecten “capaciteit” en “personeel”, uitsluitend het volgende te hebben meegedeeld:

“

Beschrijving van de technische capaciteit

In 2015 nam Medialed het beheer over van het contract voor de installatie van 18 LED-schermen dat in november 2008 door de gemeente Knokke-Heist en Juan Consulting Bvba werd ondertekend.

Sindsdien heeft zijn technische capaciteit bewezen :

- om netwerken van 18 digitale schermen in het publieke domein te installeren
- om de inhoud van deze schermen wekelijks te beheren
- om deze 18 schermen regelmatig te onderhouden
- de 18 schermen te vervangen door nieuwere (Gedaan in 2015)

Lijst van personen belast met de Opdracht

Olivier Naets, afgevaardigde bestuurder van Medialed.

.”

De beoordeling in het selectieverslag dat de verzoekende partij nalaat een beschrijving te geven van haar technische capaciteit en ondersteunend personeel en dat niet kan worden afgeleid of zij wel in staat zal zijn om tegemoet te komen aan de eisen van het bestek, die, zoals blijkt uit de omschrijving van het voorwerp van de opdracht, verder reiken dan het beheer van de thans door haar geëxploiteerde informatiedragers, lijkt de grenzen van een zorgvuldige beoordeling niet te buiten te gaan.

Wat het personeel betreft, wordt overigens enkel de afgevaardigd bestuurder als persoon belast met de opdracht vermeld, zonder

toevoeging van het gevraagde cv of opgave van een plaatsvervanger. Er wordt *prima facie* geen opgave gedaan van “de naam en het CV van de eventuele adviseurs of technici, die kunnen worden ingezet voor deze Opdracht, met vermelding van de functie, specialisatie en relevante ervaring” zoals nochtans gevraagd in de selectieleidraad.

Voorts betwist de verzoekende partij ook niet dat zij in de lopende opdracht geen rechtstreekse toegang aan de opdrachtgever biedt op haar schermen – wat thans wel wordt vereist in de omschrijving van het voorwerp van de opdracht – zodat op het eerste gezicht niet valt in te zien hoe een loutere verwijzing naar de uitvoering van een bestaande opdracht zou kunnen volstaan om haar technische bekwaamheid in het licht van de huidige opdracht aan te tonen.

Evenmin lijkt een algemene verwijzing in het kader van een voorafgaande marktbevraging dat dit technisch mogelijk zou zijn, te volstaan. Overigens lijkt in het kader van die marktbevraging dit ook niet te zijn gestaafd.

14. Het middel is niet ernstig.

C. Derde middel

Uiteenzetting van het middel

15. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 4 van de wet overheidsopdrachten 2016, artikel 65 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’, artikel 41, eerste (lees: tweede) lid, 10°, van het decreet lokaal bestuur, het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij betoogt:

“Doordat, eerste onderdeel, aan de kwalitatieve selectiecriteria van de ‘capaciteit’ en het ‘personeel’ geen gepast niveau verbonden werd;
Doordat, tweede onderdeel, deze selectiecriteria niet op duidelijke wijze geformuleerd werden en verzoekende partij verhinderden te weten op welke manier zij moest antwoorden op de selectiecriteria;
Doordat, tweede onderdeel, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Knokke-Heist de selectiecriteria ‘financiële ratio’s’, ‘capaciteit’, ‘personeel’ en ‘referenties’ anders heeft ingevuld in de

selectiebeslissing dan dat ze omschreven waren in de selectieleidraad vastgelegd door de gemeenteraad van de gemeente Knokke-Heist;
Doordat, eerste en tweede onderdeel de onwettigheid van deze bestekbepalingen ook de onwettigheid van de selectiebeslissing tot gevolg heeft die er op steunt;
Terwijl, eerste onderdeel, de aanbestedende overheid ertoe verplicht is elk kwalitatief selectie criterium te verbinden aan een gepast niveau, tenzij wanneer een van de gebruikte criteria zich daar niet toe leent;
Terwijl, tweede onderdeel, de selectiecriteria transparant moeten zijn en ze de kandidaten moeten toelaten op voorhand te weten op welke manier zij moeten antwoorden op deze criteria om geselecteerd te worden;
Terwijl, tweede onderdeel, het college van burgemeester en schepenen niet bevoegd is voorwaarden toe te voegen aan de voorwaarden van de plaatsingsprocedure vastgelegd door de gemeenteraad;
Terwijl, eerste en tweede onderdeel, de aanbestedende overheid het bestek op een zorgvuldige manier moet opstellen;
Zodat de in het middel aangehaalde bepalingen geschonden werden.”

In de toelichting bij het middel gaat de verzoekende partij bij het eerste middelonderdeel uit van een gebrek aan vaststelling van het gepaste niveau bij de selectiecriteria “capaciteit” en “personeel”. Het selectie criterium “capaciteit” schrijft volgens de verzoekende partij louter voor dat de kandidaat moet beschrijven over welke gespecialiseerde functies en mogelijkheden hij beschikt of kan beschikken om een aantal functies te verzekeren. Voor het criterium “personeel” wordt louter gevraagd naar de cv’s van de projectverantwoordelijke en de eventuele adviseurs of technici die kunnen ingezet worden voor de opdracht, zonder opgave van het aantal personeelsleden dat moet worden ingezet voor de opdracht of hun hoedanigheid, ervaring en competenties.

Bij het tweede middelonderdeel voert de verzoekende partij aan dat de aanbestedende overheid de selectiecriteria nader heeft geformuleerd in de selectiebeslissing waardoor de aanvraag tot deelneming onderworpen werd aan strengere voorwaarden dan voorzien in de selectieleidraad. Uit de omschrijving van de betrokken selectiecriteria in de selectieleidraad bleek volgens haar niet dat het bewijs moest worden geleverd van:

- de technische bekwaamheid van het personeel aangezien er louter wordt gevraagd naar een aantal gegevens van personen belast met de uitvoering van de opdracht;

- de mate waarin kan voorzien worden in softwareontwikkeling of -ondersteuning; en
- de technische ondersteuning nodig om sensoren of meetapparatuur te laten plaatsen, onderhouden en beheren in het kader van de “Smart City voorzieningen” van Knokke-Heist.

Daarnaast werd het selectie criterium van de financiële ratio's volgens de verzoekende partij vaag geformuleerd in de selectie leidraad, namelijk dat elk van de kandidaten zich in een normale financiële toestand moet bevinden waardoor zij in staat zijn deze opdracht tot een goed einde te brengen. In het selectieverslag echter werd deze “normale financiële toestand” als volgt nader verduidelijkt: “Deze ratio's mogen niet wijzen op een risico op discontinuïteit van de verplicht betrokken partijen. Er wordt aangenomen dat er een risico op discontinuïteit bestaat indien gedurende de laatste drie (3) boekjaren twee maal een negatief eigen vermogen of twee maal verlies vóór belasting wordt vastgesteld bij één of meerdere van de verplicht betrokken partijen”. Deze invulling in het selectieverslag was niet gekend bij de kandidaten op het ogenblik van het indienen van hun aanvraag tot deelneming. Ook hier werden volgens de verzoekende partij het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel geschonden. Bovendien heeft het college van burgemeester en schepenen minstens een voorwaarde toegevoegd die niet in de selectie leidraad, vastgesteld door de gemeenteraad, werd vermeld.

Ten slotte maakt ook de formulering van het criterium “referenties” in de selectie leidraad en de toepassing ervan door de aanbestedende overheid, volgens de verzoekende partij, een schending uit van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel. Het selectie criterium van de “referenties” werd op een dermate vage wijze omschreven in de selectie leidraad dat het de aanbestedende overheid heeft toegelaten de door de kandidaten gevoegde referenties te aanvaarden voor de beide percelen waaruit deze overheidsopdracht bestaat, terwijl de twee percelen een wezenlijk verschillend voorwerp hebben, aangezien het gaat, enerzijds, om het plaatsen, onderhouden en exploiteren van digitale informatiedragers en, anderzijds, over het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes.

Beoordeling

16. Wat het eerste middelonderdeel betreft, lijkt, wat het criterium “personeel” betreft, bezwaarlijk te mogen worden aangenomen dat dit criterium te vaag zou zijn geformuleerd en te dezen dan ook niet zou zijn voldaan aan de vereiste van oplegging van een minimaal niveau aangezien uitdrukkelijk in de selectieleidraad wordt bepaald dat de voorstelling van de medewerkers “minstens de volgende onderdelen” dient te bevatten: “Opgave van de naam en het CV van de projectverantwoordelijke/teamleider (met plaatsvervanger) die de Opdracht zullen bewaken en uitvoeren” en “Opgave van de naam en het CV van de eventuele adviseurs of technici, die kunnen worden ingezet voor deze Opdracht, met vermelding van de functie, specialisatie en relevante ervaring”.

Ook wat het selectiecriterium “capaciteit” betreft, lijkt de selectieleidraad op het eerste gezicht wel te bepalen op welke vlakken van de kandidaat verwacht wordt dat hij zijn capaciteit aantoont “om de Informatiedragers te plaatsen, te onderhouden en herstellen”, “om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren” en “om de rechtstreekse toegang te waarborgen die het opmaken en zenden door de Gemeente van Publieke Boodschappen zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer mogelijk maakt”.

17.1. Wat het tweede middelonderdeel betreft, meer bepaald de kritiek dat inzake de criteria “capaciteit” en “personeel” er in de selectiebeslissing strengere voorwaarden zijn opgenomen dan in de selectieleidraad, valt op dat de verzoekende partij geen kritiek uit op het eerste motief van haar niet-selectie in de selectiebeslissing, namelijk het gebrek aan opgave van de medewerkers en de minimaal vereiste onderdelen die de voorstelling ervan diende te bevatten. Dit zijn elementen die er precies toe doen om de technische bekwaamheid van het personeel aan te tonen.

Voorts lijkt de motivering in de selectiebeslissing, namelijk de verwijzing naar “softwareontwikkeling of -ondersteuning”, wel degelijk rechtstreeks verband te houden met het criterium “capaciteit” in de selectieleidraad waarbij wordt bepaald dat de gemeente rechtstreeks en zonder tussenkomst van de

opdrachtnemers via de digitale informatiedragers publieke boodschappen kan uitzenden.

Het element in de motivering van de selectiebeslissing over “Smart City voorzieningen” lijkt dan weer een uitdrukkelijke referentie aan het voorwerp van de opdracht – zie hiervoor randnummer 3.3 – en zoals onder randnummer 13 opgemerkt dient het criterium van de technische draagkracht als selectiecriterium te worden begrepen samen genomen met het voorwerp van de opdracht.

17.2. Aangaande de beweerde vaagheid van het selectiecriterium “9.1.3. voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de Opdracht te kunnen uitvoeren”, meer bepaald inzake de door de kandidaten bij te brengen financiële ratio’s, lijkt de in de selectiebeslissing vermelde motivering dat de ratio’s niet mogen wijzen “op een risico op discontinuïteit van de verplicht betrokken partijen” geenszins een voorwaarde toe te voegen aan het selectiecriterium. In de selectieleidraad wordt uitdrukkelijk bij dit criterium vermeld dat elk van de kandidaten zich in een normale financiële toestand moet bevinden waardoor zij in staat zijn deze opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Het college lijkt dan ook geen andere invulling te geven dan wat in de selectieleidraad is opgenomen. Overigens is het belang van de verzoekende partij bij deze kritiek twijfelachtig aangezien een beweerde striktere invulling van dit criterium haar niet lijkt te benadelen.

17.3. Ten slotte, wat de kritiek betreft inzake het criterium “referenties” dat hiervoor is weergegeven onder randnummer 3.4, lijkt de verzoekende partij niet te kunnen worden gevolgd in haar argumentatie dat de formulering van het betrokken selectiecriterium strijdig zou zijn met het transparantie- en het gelijkheidsbeginsel omdat de twee percelen een wezenlijk verschillend voorwerp hebben “aangezien het enerzijds gaat om het plaatsen, onderhouden en exploiteren van digitale informatiedragers en anderzijds over het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes”.

Op het eerste gezicht lijkt uit de omschrijving van deze percelen – zie hiervoor randnummer 3.3 – te mogen worden afgeleid dat in de beide

percelen moet worden gebruikgemaakt van digitale informatiedragers. Er blijkt dan ook niet waarom een omschrijving van een selectiecriterium dat verband houdt met dergelijke digitale informatiedragers en dat vooraf op gelijke wijze kenbaar was voor alle kandidaten strijdig zou zijn met de aangevoerde beginselen.

Wat de kritiek op de toepassing van dit criterium betreft, komt de beoordeling daarvan aan bod bij het tweede onderdeel van het vierde middel.

18. Het middel is niet ernstig.

D. Vierde middel

Uiteenzetting van het middel

19. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 4, eerste lid, 5°, en artikel 5, 6°, van de rechtsbeschermingswet, de formele-motiveringsplicht vervat in de motiveringswet en het materieel-motiverings-beginsel. Zij betoogt:

“Doordat, eerste onderdeel de aanbestedende overheid de kandidatuur van verzoekende partij heeft geweerd op grond van niet pertinente motieven;
Doordat, tweede onderdeel, de aanvaarding van de aanvragen tot deelneming van Clear Channel en JC Decaux voor het selectiecriterium ‘referenties’ niet werd gemotiveerd;
Terwijl elke selectiebeslissing moet steunen op motieven die worden uitgedrukt in de beslissing zelf en hun grondslag vinden in het administratief dossier;
Terwijl deze motieven feitelijk correct, pertinent en draagkrachtig moeten zijn;
Zodat de in het middel aangehaalde bepalingen geschonden werden.”

In het eerste middelonderdeel bekritiseert de verzoekende partij de motieven op grond waarvan tot haar niet-selectie werd besloten.

Op de eerste plaats is het motief dat geen documenten worden toegevoegd met betrekking tot het beroep op de draagkracht van andere entiteiten volgens haar niet pertinent nu zij geen beroep doet op de draagkracht van derden.

Daarnaast reiken volgens de verzoekende partij de bestek-vereisten niet verder dan het beheer van de thans door haar geëxploiteerde informatiedragers. Immers blijft het onderhoud, het beheer en de herstelling dezelfde of deze nu betrekking hebben op 16 schermen dan wel op 25-30 schermen waarvan er minstens twee interactief zijn. Bovendien blijkt inmiddels uit de gunningsleidraad dat de opdracht waarvan de verzoekende partij heeft kennis genomen na de selectie:

- geen betrekking zal hebben op 25-30 schermen maar wel op 22 schermen;
- deze schermen geen oppervlakte meer zullen hebben van 2 meter maar wel van ongeveer 1,5 m² (75 inch);
- geen twee interactieve beeldschermen meer zal inhouden;
- wat de meetapparatuur betreft, de eis herleid wordt tot het voorzien in ruimte in de behuizing van de schermen om deze apparatuur te installeren. Deze apparatuur zal worden aangekocht en beheerd door een derde.

Voorts, zo vervolgt de verzoekende partij, weet de aanbestedende overheid dat zij bij de huidige opdracht uitgevoerd door de verzoekende partij niet over de mogelijkheid beschikt om boodschappen rechtstreeks en zonder tussenkomst van de verzoekende partij uit te zenden en dat dit het gevolg is van een organisatorische keuze van de verzoekende partij en niet van een technische onmogelijkheid. Dat de verzoekende partij hiertoe technisch wel in staat is, werd volgens haar ook reeds bevestigd in het kader van de voorafgaande marktconsultatie.

Ten slotte wordt volgens de verzoekende partij in geen enkel van de kwalitatieve selectiecriteria een vereiste opgenomen om aan te tonen dat de nodige technische ondersteuning beschikbaar is om sensoren of meetapparatuur te laten plaatsen door de aanbestedende overheid in het kader van haar “Smart Cityproject”, zodat een eventueel gebrek aan informatie geen grond tot wering kan uitmaken. In elk geval impliceert het beheer van de schermen uiteraard ook dat er bepaalde functionaliteiten kunnen toegevoegd worden aan deze schermen. Het gaat er maar om deze apparatuur te plaatsen, mogelijkheid die zij eveneens al bevestigd zou hebben tijdens de voorafgaande marktconsultatie.

In het tweede middelonderdeel bekritiseert de verzoekende partij de motieven op grond waarvan de twee kwestieuze kandidaten werden geselecteerd. Zij verwijst daarbij ook naar het tweede onderdeel van het derde middel. In het selectieverslag wordt volgens haar nergens gemotiveerd waarom de referenties werden aanvaard voor de beide percelen ondanks het feit dat deze percelen een verschillend voorwerp hebben. In het licht van dit verschillend voorwerp rustte minstens de plicht op de aanbestedende overheid om te motiveren waarom deze referenties nuttig waren voor de uitvoering van de beide percelen.

Beoordeling

20.1. Wat het eerste middelonderdeel betreft, mag in herinnering worden gebracht dat uit de motivering in het selectieverslag in essentie blijkt dat de verzoekende partij niet geselecteerd werd omdat zij heeft nagelaten een beschrijving te geven van haar technische capaciteit en ondersteunend personeel en dat aldus niet kon worden beoordeeld of zij wel in staat zal zijn om tegemoet te komen aan de eisen van het bestek die verder reiken dan het beheer van de thans door haar geëxploiteerde informatiedragers.

20.2. In de mate dat de verzoekende partij in het kader van het eerste onderdeel een schending van de formelemotiveringsplicht aanvoert, lijkt het op het eerste gezicht voor de verzoekende partij op grond van het selectieverslag mogelijk te zijn geweest om voldoende inzicht te krijgen in de redenen van haar niet-selectie. Dit blijkt overigens ook uit haar verzoekschrift zelf.

20.3. Het komt in de eerste plaats toe aan de aanbestedende overheid om de voorgelegde informatie en documenten inzake de technische bekwaamheid te beoordelen op hun overeenstemming met het gevraagde in de selectieleidraad, waarbij zij ter zake lijkt te beschikken over een zekere beoordelingsruimte. Wel dient de aanbestedende overheid bij die beoordeling de regels die zijzelf heeft vastgelegd in de opdrachtdocumenten te respecteren, alsook de beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel.

20.4. Ten opzichte van wat de verzoekende partij in haar aanvraag tot deelneming met betrekking tot de criteria “capaciteit” en “personeel” heeft

vermeld – weergegeven onder randnummer 13 – valt op – zoals ook reeds opgemerkt onder randnummer 17.1 – dat de verzoekende partij geen kritiek geeft op het eerste motief in de selectiebeslissing om haar niet te selecteren.

Voorts lijkt de vaststelling in die beslissing dat de verzoekende partij geen beroep doet op de draagkracht van derden wel pertinent. Aldus blijkt dat zij om te voldoen aan de voormelde criteria zich uitsluitend lijkt te beroepen op haar eigen capaciteit en personeel.

Evenzeer kan de verzoekende partij niet worden gevolgd, zoals reeds geoordeeld is onder randnummer 13, in haar opvatting dat “de bestekvereisten niet verder [reiken] dan het beheer van de thans door verzoekende partij geëxploiteerde informatiedragers”. Een loutere verwijzing naar haar uitvoering van de lopende opdracht volstaat dan ook niet. Wat de argumentatie op grond van de gunningsleidraad betreft, mag deze worden verworpen omdat de verwerende partij ertoe gehouden was haar beslissing te nemen overeenkomstig de bepalingen van de selectieleidraad.

In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar de marktbevraging, lijkt zij eraan voorbij te gaan dat zij hier vooral zelf is tekort geschoten aan haar plicht tot een zorgvuldige indiening van haar kandidatuur. De verzoekende partij heeft overigens bij deze marktbevraging haar capaciteit evenmin gestaafd.

Evenzo dient de kritiek van de verzoekende partij aangaande de bewijslevering van de technische ondersteuning nodig om sensoren of meetapparatuur te laten plaatsen, onderhouden en beheren in het kader van de “Smart City voorzieningen” van de gemeente Knokke-Heist te worden verworpen. In de omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt zeer nadrukkelijk naar deze “Smart City voorzieningen” verwezen en, zoals reeds meermaals overwogen, dienen de selectiecriteria samen met dit voorwerp te worden begrepen.

20.5. De conclusie voor dit middelonderdeel is dan ook dat de verzoekende partij niet aantoont dat de motivering ondeugdelijk is.

21. Wat het tweede middelonderdeel betreft, valt naast wat reeds werd overwogen bij de beoordeling van het tweede onderdeel van het derde middel, het volgende op te merken om tot de verwerping ervan te besluiten.

Wat de aangevoerde schending van de formelemotiveringsplicht betreft, wordt in het selectieverslag bij de kandidaten nv JC Decaux en bvba Clear Channel “Ok” vermeld samen met de door deze kandidaten bijgebrachte referenties. Deze uitdrukkelijke motivering lijkt hier afdoende.

Voorts blijkt op het eerste gezicht nergens uit de gestelde selectie-eis over de referenties dat voor beide percelen afzonderlijke referenties dienden te worden bijgebracht en dus evenmin dat de selectiebeslissing dienovereenkomstig diende te worden gemotiveerd. Minstens toont de verzoekende partij niet afdoende aan dat de voorgelegde referenties in het licht van de gestelde eis geen betrekking zouden kunnen hebben op beide percelen; zoals blijkt uit de omschrijving van de percelen van de opdracht, omvat ook perceel 2 informatiedragers.

22. Het middel is niet ernstig.

VI. Besluit en kosten

23. Geen van de middelen is ernstig gebleken. De vordering dient te worden verworpen.

Op de vraag van de verwerende partijen om de verzoekende partij te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro voor elk van hen, wordt niet ingegaan. De beide verwerende partijen worden bijgestaan door dezelfde raadslieden en beiden hebben een identiek belang laten blijken.

BESLISSING

1. De Raad van State verwerpt de vordering.

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van 20 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partijen.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van vijftientwintig februari tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Pierre Barra,	staatsraad, waarnemend voorzitter,
bijgestaan door	

Greta Scheveneels,	griffier.
--------------------	-----------

De griffier

De voorzitter

Greta Scheveneels

Pierre Barra